

1500392-11.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... estava realizando uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes, e diligenciou até a Avenida Jerônimo de Camargo, local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram, em uma viela, dois indivíduos, um deles levando duas pochetes, uma a tiracolo e outra na cintura, bem como uma sacola de mercado, na mão, situação típica do tráfico, então ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500392-11.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500392-11.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL KAUÃ DA SILVA NASCIMENTO SEREJO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

DANIEL KAUÃ DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 07 de abril de 2022, por volta das 10h30min, na Avenida Gerônimo de Camargo, 7950, Jardim Cerejeiras, nesta cidade e Comarca de Atibaia, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 72 porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, 77 porções de crack e 08 porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, policiais civis realizavam diligências em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ocasião em que avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles, o ora réu, portava uma sacola e duas pochetes.

Ao perceber que seriam abordados, os indivíduos empreenderam fuga, mas DANIEL foi detido. Realizada busca pessoal, foram encontradas, no interior das pochetes e da sacola que ele trazia consigo, as drogas acima descritas, além de R\$ 152,00 em notas trocadas.

Indagado, DANIEL confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo consta, evidente, pela quantidade e variedade das drogas, pelo numerário apreendido e pela informal confissão, que as substâncias encontradas

pertenciam ao réu se destinavam ao comércio ilícito.

O réu foi posto em liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares (fls. 51/55). Alvará de soltura às fls. 59/60.

O réu constituiu advogado (fls. 106), que apresentou defesa prévia (fls. 101/105), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 114/117).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final (fls. 158/159).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 165/172).

Às fls. 173, o réu foi dado por citado na pessoa de seu patrono.

Em memoriais finais, a defesa do réu requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, bem como a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, requerendo, ainda, a fixação do regime de cumprimento aberto ou semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade (fls. 178/187).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 15/18 e 30/34), no auto de exibição/apreensão (fls. 19), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 20), nas fotografias (fls. 90/92), nos laudos periciais (fls. 87/93, 133/135, 136/138 e 139/141), e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, acompanhado de seu advogado, disse que, de fato, fato estava traficando havia uma semana, porque estava passando por necessidades; pediu as contas do emprego no Big de Atibaia e estava com passagem comprada para o Maranhão para o final do mês, mas que começou a passar por dificuldades e precisou traficar, sendo que está arrependido (fls. 09).

Em juízo, interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que estava passando por dificuldades; estava trabalhando no Big e pediu demissão, tendo comprado uma passagem com o dinheiro da rescisão; estava se mantendo com esse dinheiro, no entanto, estava passando por dificuldades, e apareceu a oportunidade de vender drogas, então foi traficar, para não passar fome; tentou arrumar "bicos" e emprego, mas não conseguiu; questionado para onde comprou a passagem, disse que para voltar para o Maranhão, em março; questionado por que estava traficando em abril, se a passagem era para março, disse que estava sem dinheiro, passando por dificuldades; questionado por que não foi embora para o Maranhão, se falou que a passagem que comprou era para março, disse que errou, a passagem era para depois de abril; questionado por que ainda não foi embora, disse que entrou no "corre", tendo sido preso após uma semana, e não teve tempo para ir embora; questionado se estava preso quando a passagem venceu, disse que já tinha sido preso, e não podia sair de Atibaia; nunca teve passagens criminais, nem quando era menor; veio do Maranhão em 2019, para jogar bola, tendo parado de treinar em 2021, então conseguiu o emprego no Big, em Atibaia; tem dezenove anos de idade; morava com uma mulher; veio para Atibaia para jogar bola, sendo que morava sozinho e, depois que entrou no emprego, conheceu a mulher, que era sua amiga, e foram dividir o aluguel, sendo que havia um quarto para cada um; possui o ensino médio completo; às reperguntas da defesa, disse que está arrependido; questionado se veio do Maranhão para São Paulo para jogar bola, e permaneceu alojado até 2021, no alojamento do clube de futebol em que estava jogando, disse que "isso"; questionado se, quando foi dispensado, foi morar com a mulher, disse que "isso"; conseguiu um emprego em Atibaia, e foi morar com ela (fls. 158/159).

A testemunha Sinésio Ribeiro, policial civil, ouvida às fls. 158/159, disse que estava realizando uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes, e diligenciou até a Avenida Jerônimo de Camargo, local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram, em uma viela, dois indivíduos, um deles levando duas pochetes, uma a tiracolo e outra na cintura, bem como uma sacola de

mercado, na mão, situação típica do tráfico, então realizou a abordagem, ocasião em que o indivíduo que estava sem nada saiu correndo, sendo que DANIEL também tentou se evadir, tendo sido necessário o uso de força moderada, razão pela qual o réu acabou lesionado, o que também aconteceu com a equipe, por causa de um muro que havia no local; em revista às pochetes e à sacola, foram encontrados os entorpecentes, totalizando 72 pedras de crack, 78 "buchas" de maconha e 07 porções de cocaína, além de R\$ 152,00 em dinheiro; indagado, o réu admitiu que estava traficando havia alguns dias, e alegou que estava passando por dificuldades financeiras, tendo dito, também, que era do Maranhão, e que havia comprado uma passagem para voltar para o estado; o réu foi conduzido até a autoridade policial e, em seu interrogatório, feito na presença do advogado, confessou o tráfico; questionado se já conhecia o réu de outras abordagens, disse que não conhecia; às reperguntas da acusação, questionado se o local em que o réu foi preso é próximo a alguma escola ou algum parque, disse que não; questionado se o local é de grande movimentação, disse que sim, é uma avenida, sendo que ficava ao lado de um bar. A testemunha Wagner Almeida Gregório, policial civil, ouvida às fls. 158/159, disse que o local já é conhecido como ponto do tráfico de entorpecentes; estava em viatura descaracterizada no local, juntamente com seu parceiro, quando, em dado momento, observaram o réu, juntamente com outra pessoa, sendo que DANIEL carregava uma sacola plástica em uma das mãos, e tinha, também, uma pochete em sua cintura, e outra pochete no seu pescoço; resolveram abordar o réu, ocasião em que a outra pessoa com ele empreendeu fuga, sendo que o réu também tentou fugir, tendo sido contido, e a sacola plástica caiu no chão; conseguiram algemar o réu e, verificando a sacola que estava na mão do réu, e que caiu ao solo, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes; havia, também, entorpecentes nas duas pochetes que o réu levava consigo, sendo que havia, ainda, dinheiro na pochete que estava na cintura de DANIEL; questionado se já conhecia o réu de outras abordagens, disse que não; questionado se o réu disse há quanto tempo estava traficando no local, disse que ele disse que estava traficando no local havia pouco tempo, e alegou que estava passando por dificuldades financeiras.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, interrogado em fase policial e em juízo, confessou os fatos, narrando, em síntese, que estava passando por dificuldades, e resolveu traficar drogas. A confissão veio corroborada pelos relatos dos policiais, que narraram, em síntese, que visualizaram o réu, em local conhecido como ponto do tráfico, levando consigo uma sacola e duas pochetes, juntamente com outro indivíduo, que empreendeu fuga, tendo o réu sido detido. Disseram, também, que foram encontrados, nas pochetes e na sacola que o réu levava consigo, entorpecentes, bem como R\$ 152,00 em dinheiro. O policial Sinésio disse, também, que as drogas encontradas totalizavam 72 pedras de crack, 78 "buchas" de maconha e 07 porções de cocaína. Ambos os policiais disseram, ainda, que o réu admitiu que estava traficando, alegando que estava passando por dificuldades financeiras, sendo que não conheciam DANIEL de outras abordagens. Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no

sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não conheciam o réu e que não tinham, mesmo, qualquer interesse maior na sua gratuita acusação.

Assim, toda a prova colhida dá conta de que o réu estava mesmo na traficância, tanto é que admitiu a prática quando foi abordado pelos policiais, e confessou o crime em solo policial e em juízo, confissão que veio corroborada pelos firmes relatos dos policiais, bem como pelos laudos periciais acostados aos autos, de modo que a conduta de DANIEL se amolda perfeitamente à descrição do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo a condenação medida que se impõe.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes (fls. 35/37).

Culpabilidade normal à espécie. Não há informações sobre sua conduta social ou personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas. Quanto à natureza e quantidade do produto, nada a considerar.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Não há informes sobre a atual situação financeira do réu. Assim, o valor do dia-multa deverá ser fixado no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes.

Há a atenuante da confissão, prestada pelo réu em solo policial e em juízo, bem como a atenuante da menoridade relativa, já que o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 07). No entanto, em observância à Súmula 231, do STJ, a pena não pode ser atenuada aquém do mínimo, devendo ser mantida no patamar fixado. Na última fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Considero incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Não obstante seja tecnicamente primário, o réu foi surpreendido em posse de elevada quantidade de entorpecentes, quantia que não seria confiada a alguém que não tivesse profundo envolvimento com o ilícito, além de R\$ 152,00, cuja origem lícita não foi comprovada, estando evidente que se dedicava às atividades criminosas. Outrossim, trazia consigo anotações para o tráfico, indicando envolvimento profundo com o ilícito, até porque não tinha qualquer ocupação lícita, fazendo do tráfico seu modo de vida.

Ademais, traficando crack, o réu fazia parte de uma cadeia de criminosos envolvidos desde a produção do entorpecente até sua aquisição pelo usuário. Dedicava-se, portanto, à prática de atividade criminosa consistente em traficância, não fazendo

jus ao benefício do parágrafo 4º.

Neste sentido: "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(...) 7. Não há que se falar no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois está provado que o réu se dedica a atividades criminosas, haja vista terem sido encontradas em seu poder 34 pedras de "crack", sendo o encarregado, justamente, da disseminação, propriamente dita, das substâncias entorpecentes, que de mais a mais não consta fossem por ele produzidas. Por sinal, para a produção do "crack", reclama-se toda uma estrutura técnica, laboratório químico, posse de substâncias químicas, que também não consta fossem mantidos pelo réu, de modo que, necessariamente, como acima adiantado, está ele inserido na ponta final de uma corrente criminosa. Precedentes do STF. (...)” (TJ-SP - APL: 00496557320118260577 SP 0049655-73.2011.8.26.0577, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/09/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/09/2014).

Por fim, não se pode ignorar o grande dano que vem sendo causado pelos supostos 'pequenos traficantes'.

A ilusão de que eles são figuras socialmente inofensivas, não pode cegar o entendimento do julgador, a quem a lei deu a faculdade de aplicar o benefício do parágrafo 4º, não havendo direito subjetivo do réu à sua aplicação. E não se justifica o argumento de que o crime é praticado sem violência ou grave ameaça, e de que o réu é primário e de bons antecedentes.

Primeiramente, o fato de o réu ter sido PEGO pela primeira vez, não quer dizer que ele esteja PRATICANDO o fato criminoso pela primeira vez.

Outrossim, por trás de todo 'pequeno traficante', há os grandes fornecedores. A função do intitulado 'pequeno traficante' é primordial na cadeia criminosa, sendo que o fracionamento do tráfico vem sendo usado como artifício dos traficantes em geral, inclusive, como forma de terem suas condutas desclassificadas para uso próprio, diante da pequena quantidade encontrada em seu poder, fazendo com que muitos julgadores absolvam os grandes responsáveis pela entrega das drogas aos viciados: 'o traficante de porta de escola', o 'pequeno traficante', o 'traficante-viciado'.

No entanto, a conduta deles deve ser analisada com o devido rigor.

Conforme brilhante explanação de EDILSON MOUGENOT BONFIM, Doutor em Direito Processual Penal, Professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e Escritor: "Costuma-se dizer que grande parte dos presidiários hoje - e se justifica o aumento da população carcerária também por isso -, que grande parte dos presidiários, advém do 'pequeno tráfico de drogas' e que nós deveríamos ter uma política criminal voltada ao encarceramento 'do grande traficante' - tenho visto isto com a certa recorrência de declarações de autoridades na mídia. Não sei como se faz essa distinção de 'pequeno traficante' para 'grande traficante', ao ponto do 'grande' merecer a prisão e o 'pequeno' não. Um 'grande traficante' não vai ele próprio traficar, levar 10 toneladas de cocaína ao local. Ele se vale dos 'pequenos' para a distribuição. Todo soldado que entra neste exército quer ser General, e se o Estado premiar, no primeiro dos seus delitos, de tráfico, ainda que 'pequeno', será como que um prêmio, um incentivo, para que ele busque o 'generalato', afinal de contas, o Estado estará lhe passando a mão na cabeça, como recomendam, uns tantos quantos gênios do Direito, que não conseguiram baixar, com as suas ideias, a criminalidade em local nenhum do mundo. Foi preciso que um homem quebrasse o paradigma mundial, destes que especulavam com discursos penais, e diziam que nós deveríamos tratar com blandícia aquele que cometer o 'pequeno crime', que nós deveríamos tratar com comiseração o 'pequeno delinquente'. Nós tínhamos, então, uma matriz piedosa, que dizia que o Estado não tinha legitimidade de punir aquele que cometesse um 'pequeno delito'. Um homem quebrou esse paradigma, não farei um elogio vazio (...), farei um elogio pautado naquilo que é história. Nova Iorque, antes e depois de Rodolfo Juliani. Antes, tomada por gangues, onde

havia criminalidade imperando em todos os quadrantes sociais e a política de Tolerância Zero, que até um Presidente Francês, socialista, mandou seus estudiosos para trazer a 'tolérance zéro' para França, modelo que foi discutido mundialmente com este homem, que quebrou o paradigma e disse: 'Tolerância Zero desde o primeiro delito, porque nós assim temos verdadeira piedade do Homem', nós impediremos que ele componha uma 'sinfonia criminoso musical' no futuro, porque já no primeiro delito, na primeira 'nota musical criminoso', nós o puniremos, e aí ele saberá que existe o Estado para punir aquilo que, muitas vezes, faltou autoridade paterna, faltou autoridade escolar, faltou alguma autoridade que é preciso chegar o Estado com a sua voz, com a sua força, com os seus regramentos, para fazer alguma verdade imperar. Então, o equívoco que se recita é se tratar 'pequeno criminoso', 'pequeno traficante' e 'grande traficante', e só o segundo estaria sujeito à prisão. Ora, o 'pequeno' ele anda de acordo com as suas 'pernas financeiras'. Ele não é grande, não é porque ele tem escrúpulos, é porque ele não pode. Ele trafica 100 gramas porque ele não pode traficar 10 toneladas. Se ele pudesse, ele o faria. O dolo é o mesmo. Ontologicamente, o ser criminoso e a danosidade social que isto provoca ou impacta, é a mesma. O 'grande traficante' se vale da sua rede de 'pequenos traficantes'. E se o Estado ficar com comiseração com relação ao 'pequeno', ele estará dizendo: 'podem ter mil abelhas trabalhando, que eu farei vistas grossas, desde que eu consiga pegar alguém maior'. Isto vai acontecer cada vez mais o fracionamento do tráfico. Será um incentivo e será uma antipolítica de inteligência criminal. Nós não devemos esquecer que aquele que mata um, como que é aquele que mata, e pratica o crime de homicídio, estão ambos sujeitos às penalidades de prisão, por ter praticado o homicídio. Ontologicamente, quem trafica pouco, ou quem trafica muito, pratica o mesmo crime. Se esta pauta ou esta inteligência valer para esse tipo de crime, nós também vamos começar a dizer: 'olha, matou só um, não vale a pena de prisão; estuprou só uma, não valeria a pena de prisão'. E isto é, me parece, a anti-inteligência do Direito Penal, quando nós esquecemos, neste momento, do que seja a danosidade social deste crime de tráfico de drogas e do que ele pode acarretar recebendo um verdadeiro incentivo do Estado. É verdade, nenhum de nós fica feliz em assistir à punição de um traficante. Creio que não. O homem não deve se comprazer com a dor alheia - e sempre haverá dor àquele punido -, mas, como no velho poema de Augusto dos Anjos: 'a mesma mão que bate, é a mesma mão que acaricia'. Aqueles que não respeitam os regramentos de conveniência de uma sociedade politicamente organizada, à qual chamamos de Estado, nós precisamos chamar alguma força do Estado, para restabelecimento da ordem, sob pena de nós deixarmos a justiça por conta própria, a critério de cada qual. Há um pensamento, de cunho religioso, recitado desde sempre: 'quem tem piedade dos seus lobos, perderá suas ovelhas'. Quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, não pense somente no 'grande traficante'. Pode ser que apenas um, o pipoqueiro da escola, viciie o seu filho. E quando seu filho estiver viciado, e o futuro dele destruído, você entenderá que o 'pequeno' também pode ser um 'grande traficante', que levou o que de mais precioso você tem na vida, a sua descendência, a próxima geração" (fonte: youtu.be/1Pb_2RG_gcY).

Assim, verifica-se que todo "pequeno traficante" faz parte de uma imensa rede, chamada crime organizado, sendo eles a ponta danosa do iceberg, por serem quem leva a droga aos usuários, expondo a vida e saúde deles. Por tal razão, não há que se falar em tráfico privilegiado, por se dedicar o réu às atividades criminosas. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -,

tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensejar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende - eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente - geralmente identificado como o "pequeno traficante" - deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio "varejista" das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminoso ligada ao narcotráfico - prática delitativa que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante - a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 - pelo gerente de "boca" ou por associados a organizações criminosas - pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"(...) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em pena restritiva de direitos" constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis

pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpro ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno DANIEL KAUÃ DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, regime fechado e multa de 500 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

O réu foi posto em liberdade provisória e não há fatos novos que autorizem a decretação de sua prisão preventiva no presente feito, motivo pelo qual poderá aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, mantidas as medidas cautelares fixadas pela decisão de fls. 51/55.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, caso o réu seja beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I. e C.

Atibaia, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA